

1508798-76.2022.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. FATO DELITUOSO DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). NULIDADES NO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] consoante orientação jurisprudencial deste Sodalício o denominado encontro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapecerica da Serra
Foro de Itapecerica da Serra
4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508798-76.2022.8.26.0268 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508798-76.2022.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253999/2022 - DEL.POL.JUQUITIBA, 27474477 - DEL.POL.JUQUITIBA, 2253999 - DEL.POL.JUQUITIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DA CUNHA MELO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

WAGNER DA CUNHA MELO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, conforme fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 71/72).

Oferecida a denúncia (fls. 72/75), esta foi recebida (fls. 76) e o requerido foi citado.

Após defesa escrita (fls. 102/109), o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 125/126).

Laudo pericial (fls. 95/98).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A alegação da defesa técnica de que a busca e apreensão foi ilegal não prospera, conforme esclareço abaixo.

A busca e apreensão domiciliar realizada no local dos fatos decorreu de decisão proferida pelo MM Juízo da 3ª Vara de Itapeverica da Serra, no âmbito do processo 1508763-19.2022.8.26.0268, decorrente de investigação de crimes que envolvem violência doméstica, conforme decisão de fls. 28/30 daqueles autos.

E, embora a busca destinasse à localização de mídias que comprovassem a autoria e materialidade de outros crimes, o encontro fortuito de prova de outra infração penal não torna o flagrante ilegal, mormente no caso em tela, em que o crime pelo qual o réu foi autuado possui natureza permanente.

Com efeito, “contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ver os crimes, para solicitar, a posteriori, um novo mandado específico de busca e apreensão”, especialmente porque não houve desvirtuamento da busca que estava sendo levado a efeito, uma vez que os agentes encontraram a arma de fogo enquanto procuravam por dispositivos que continham mídias.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. FRAUDE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIME MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO A HOMICÍDIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE AOS CORRÉUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. HIPÓTESE DE DESCOBERTA FORTUITA DE PROVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

[...]

4. A jurisprudência desta Corte entende que não é ilícito o uso de prova decorrente do seu encontro fortuito, sendo válidos os elementos obtidos casualmente, por ocasião do cumprimento autorizado de medida de obtenção de prova relativa a outro delito, ainda que inexistia conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e que este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. (AgRg no REsp 1752564 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Desse modo, incide o óbice da Súmula 83 do STJ.

[...]

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1933067/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. FATO DELITUOSO DESCOBERTO A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM RELAÇÃO A TERCEIRO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). NULIDADES NO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] consoante orientação jurisprudencial deste Sodalício o denominado encontro fortuito de provas (serendipidade) é fato legítimo, refletido, no caso

concreto, na descoberta, em interceptação telefônica judicialmente autorizada, do envolvimento de pessoas diferentes daquelas inicialmente investigadas, não gerando irregularidade a macular o Decreto de custódia cautelar ou o inquérito policial. Precedentes. 3. Recurso em habeas corpus não provido.

(STJ; RHC 77.003; Proc. 2016/0266807-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 23/10/2018; DJE 09/11/2018; Pág. 1730)

Dessa forma, considerando a ocorrência do fenômeno da serendipidade, não há qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do réu nem nos atos dela decorrente.

Não há outra questão preliminar a ser apreciada.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, embora tenha restado devidamente comprovado que o acusado, de fato, possuía a arma de fogo descrita nos autos, a conduta praticada se subsume ao tipo penal do artigo 14 da Lei 10.826/03.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, quanto ao réu, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelo relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão (fls. 22/28), pelas fotografias (fls. 29/33), pelo relatório final (fls. 66/67), pelo laudo pericial (fls. 95/98) realizado sobre a arma de fogo e cartucho apreendidos - o qual apontou se tratar de um revólver, de calibre nominal .32 INS, em perfeito estado de funcionalidade -, bem como pela prova oral nos autos produzida.

Com efeito, os Policiais Civis Alexsandro Sousa de Oliveira, Cassiano Felipe Araujo, José Marcelo Rabelo e Alexandre Augusto Madureira, quando inquiridos em juízo, disseram que foram cumprir mandado de busca e apreensão porque o acusado era investigado por quebra de medida protetiva e crime de stalking.

Asseveraram que durante a diligência localizaram um revólver dentro da gaveta de uma escrivaninha.

O Policial Alexsandro asseverou que a numeração que constava na arma não se adequava a nenhuma correspondente ao objeto. Os demais agentes destacaram que havia uma câmera no mesmo local, a qual foi entregue ao advogado do réu, pois estava quebrada.

E as falas dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejada com os depoimentos prestados por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP - AC

-Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

"Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in "Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

O réu, quando interrogado, negou a prática do crime, asseverando que o flagrante foi forjado e que nunca teve arma de fogo.

Declarou os policiais são seus inimigos porque denunciou o delegado pelo fato de que os inquéritos não andam.

Informou que é reincidente em peculato e que não possui passagem por violência doméstica.

Pois bem.

Sobre o crime em tela, salienta-se que "O tipo penal de porte ou posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública. Relevante é a manutenção do nível de segurança pública que, no caso, foi rebaixado. Portanto, a simples prática da conduta acarreta presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer situação efetiva".

No particular, o denunciado possuía 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre .32 INA, bem como 06 (seis) cartuchos íntegros. Além disso, o armamento estava em perfeito estado de funcionalidade, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 95/98.

Nessa esteira, inclusive, a prova oral é firme ao esclarecer que os agentes encontraram a arma de fogo dentro de uma gaveta na residência do réu, sendo que nada faz crer que os policiais imputaram gratuitamente ao acusado a autoria do crime, mormente porque não há qualquer prova que desabone a versão dos agentes.

Deveras, "os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

No entanto, malgrado conste na denúncia que a arma estava com a numeração suprimida, o laudo pericial de fls. 95/98 não aponta a existência de indicativos de supressão do número de identificação da arma.

Verdade que a prova oral dá conta de conta de algum problema quanto à identificação da arma por meio da numeração. E, por tudo que já esclareci, não se duvida do que os policiais afirmaram no particular.

Mas tal precisaria ser mais bem esclarecido por meio de perícia técnica, o que inocorreu.

Dessa forma, como a acusação não se desincumbiu integralmente do seu mister probatório, de rigor a desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, uma vez que o calibre nominal da arma de fogo é de uso permitido.

Assim, diante de elementos de convicção e das provas obtidas durante a instrução, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal acima descrito, sendo sua condenação, nesses termos, medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que exclua o crime ou o isente de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno WAGNER DA CUNHA MELO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Não há nenhuma circunstância a ser sopesada na primeira fase de fixação da pena, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico a existência da agravante relativa à reincidência (art. 61, inc. I, do CP), conforme certidão de fls. 140/148, pelo que agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

E, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, chego à pena total e definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

O regime inicial do cumprimento de pena para o crime é o SEMIABERTO, diante da reincidência que o acusado ostenta.

Deixo de aplicar o disposto na Lei nº 12.736/2012, ressalvando que o tempo de prisão em flagrante ou preventiva será oportunamente considerado para fins de detração. Ademais, este juízo de conhecimento não possui dados concretos para análise dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória.

Inferre-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, pois não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do réu, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Diante da reincidência do acusado, a pena privativa de liberdade imposta não pode ser substituída por pena restritiva de direitos (art. 44, II, do CP).

Pelas mesmas razões, não cabe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que “diante do recrudescimento da violência e

da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva do réu, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Itapecerica da Serra, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA